

1500100-44.2020.8.26.0400

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Luiz de Abreu Costa

Comarca: Olímpia

Foro: Foro de Olímpia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... a efetiva prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD), equiparado ao tráfico ilícito de drogas (art. 33, § 1º, da LD) ou de tráfico ilícito de maquinismos relacionados ao processamento de drogas (art. 34, caput, da LD).

Daí ser desnecessário apreender a droga ou examiná-la.

Valho-me, pois, dessa explicação.

Nos termos do art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia - Vara Criminal

Praça Monteiro Lobato, 377, Centro - CEP 15400-000, Fone:

(17)3281-1927, Olímpia-SP - E-mail: olimpiacr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30 às 19h

1500100-44.2020.8.26.0400 - lauda

Conclusos os autos ao MM. Juiz em 28 de novembro de 2022.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500100-44.2020.8.26.0400

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada José Carlos de Oliveira, devidamente qualificada, como incurso no art. 33, § 1º, III, c.c. o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) e art. 35, caput, c.c. o art. 40, VI, da LD (fls. 100/102).

Determinou-se o processamento (fls. 108/111).

A parte processada, devidamente notificada (fls. 220), apresentou resposta escrita (fls. 248/258). Argumentou, ao lado de questões preliminares ao recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, a denúncia foi recebida em 26 de outubro de 2021 (fls. 263/266) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e

juízo.

A parte processada foi citada pessoalmente (fls. 327).

Em audiência (fls. 337/338 [TA]), foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação e uma pela defesa; ao final, a parte processada foi interrogada.

Declarou-se encerrada a instrução (v. TA).

Em alegações finais (fls. 355/360), o Ministério Público requereu a procedência parcial da ação penal, argumentando que estão provadas a materialidade do contexto fático denunciado previsto no art. 33 da LD e a autoria delitiva, porém, com relação ao contexto fático denunciado previsto no art. 35 da LD, não existe prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, do CPP).

De sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Habeas Corpus Criminal n. 2257842-55.2019.8.26.0000, da 3ª Vara Judicial da Comarca de Bebedouro – Rel. Des. REINALDO CINTRA TORRES DE CARVALHO, V.U., j. 25/01/2020), argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386 do CPP); na hipótese de condenação, a aplicação da pena com observância das circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena previstas em lei (fls. 363/373).

II – DOS FUNDAMENTOS

Antes de discutir o mérito, não há alegação preliminar.

2.1 Da materialidade dos fatos e da autoria delitiva

A ação penal é improcedente.

Certa a materialidade do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 03/07, 19/23 e 133/136 [BO]), do auto de exibição e apreensão (fls. 08/09, 24/25 e 55/56 [AEA]), das Cédulas de Identidade e Certidão de Nascimento (fls. 13 [CI], 14 [CI] e 15 [CN]) e dos laudos periciais toxicológicos provisório (fls. 35/36) e definitivo (fls. 334/335 [LPTox]), a autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), não segue a mesma sorte de certeza (demonstração e comprovação).

Contextualizo e, ao final, explico.

A testemunha Milton Vieira Filho, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 03/04), que: "presentes nesta Unidade Policial, os policiais militares Sargento Vieira e Soldado Dameto comunicando que nesta data se encontravam em patrulhamento, quando receberam denúncia anônima versando sobre tráfico de drogas, onde o delator informava que na residência situada na rua da Congada, nº 59, no bairro Jd São Francisco, nesta cidade, como local de venda de entorpecentes, foi informado que um sujeito de vulgo "Marcinho" seria o dono do entorpecente. A denúncia informava que na residência estavam três jovens "preparando" a droga para ser comercializada, diante da situação se deslocaram até o local para averiguar aquela denúncia, chegando no local conversaram com vizinhos, os quais informaram que a pessoa que mora na casa é JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA e que o referido não se fazia presente no imóvel, porém ao averiguarem o imóvel pelo lado externo, através do vitrô da sala, puderam perceber uma movimentação no interior da casa e ao adentrarem pela porta da cozinha surpreenderam três jovens no ato de preparação e embalagem das drogas, foi encontrado um prato contendo várias pedras amareladas picadas aparentando ser crack, uma pedra maior da mesma coloração semelhante ao entorpecente crack, além de vários cordões de pedras amareladas aparentando crack, já fracionadas conforme é praticado no tráfico de entorpecentes.

Foi constatado que se tratavam de três adolescentes sendo eles Maicon Gabriel Alves Miranda, Estevão Aparecido de Souza Silva e Richard Ricardo Nery da Rocha, os jovens foram indagados sobre o entorpecente e informaram que foram até São José do Rio Preto onde adquiriram o entorpecente para posterior venda, todos foram detidos, em seguida foram até outra residência, no caso, a moradia de Maicon Gabriel, pois na denúncia informavam que a droga pertencia ao genitor dele, de nome Marcio Alves ,onde encontraram uma quantia em dinheiro trocada no valor de R\$ 202,85 (DUZENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), foi apurado que o imóvel utilizado pelos adolescentes para preparar a droga é de propriedade do investigado José Carlos de Oliveira, mas o referido não foi localizado pela equipe policial e apenas qualificado na ocorrência, observando que os adolescentes estavam bem a vontade no imóvel e inclusive havia uma panela de arroz no fogão, ainda quente, que provavelmente seria consumida pelos jovens. O dono da casa, José Carlos de Oliveira, não compareceu ao local mas conseguiram encontrar um documento de identidade dele no imóvel, permitindo assim sua devida identificação. Foram localizadas embalagens plásticas semelhantes as que embalavam o entorpecente, uma faca, Gillettes, também foi apreendido um telefone celular de uso pessoal do adolescente Richard, diante da localização das drogas e demais objetos tudo foi apreendido e conduziram todos ao plantão policial ocasião em que cientificaram Autoridade". Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Alessandro Dameto, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 03/04), que: "presentes nesta Unidade Policial, os policiais militares Sargento Vieira e Soldado Dameto comunicando que nesta data se encontravam em patrulhamento, quando receberam denúncia anônima versando sobre tráfico de drogas, onde o delator informava que na residência situada na rua da Congada, nº 59, no bairro Jd São Francisco, nesta cidade, como local de venda de entorpecentes, foi informado que um sujeito de vulgo "Marcinho" seria o dono do entorpecente. A denúncia informava que na residência estavam três jovens "preparando" a droga para ser comercializada, diante da situação se deslocaram até o local para averiguar aquela denúncia, chegando no local conversaram com vizinhos, os quais informaram que a pessoa que mora na casa é JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA e que o referido não se fazia presente no imóvel, porém ao averiguarem o imóvel pelo lado externo, através do vitrô da sala, puderam perceber uma movimentação no interior da casa e ao adentrarem pela porta da cozinha surpreenderam três jovens no ato de preparação e embalagem das drogas, foi encontrado um prato contendo várias pedras amareladas picadas aparentando ser crack, uma pedra maior da mesma coloração semelhante ao entorpecente crack, além de vários cordões de pedras amareladas aparentando crack, já fracionadas conforme é praticado no tráfico de entorpecentes. Foi constatado que se tratavam de três adolescentes sendo eles Maicon Gabriel Alves Miranda, Estevão Aparecido de Souza Silva e Richard Ricardo Nery da Rocha, os jovens foram indagados sobre o entorpecente e informaram que foram até São José do Rio Preto onde adquiriram o entorpecente para posterior venda, todos foram detidos, em seguida foram até outra residência, no caso, a moradia de Maicon Gabriel, pois na denúncia informavam que a droga pertencia ao genitor dele, de nome Marcio Alves ,onde encontraram uma quantia em dinheiro trocada no valor de R\$ 202,85 (DUZENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), foi apurado que o imóvel utilizado pelos adolescentes para preparar a droga é de propriedade do investigado José Carlos de Oliveira, mas o referido não foi localizado pela equipe policial e apenas qualificado na ocorrência, observando que os adolescentes estavam bem a vontade no imóvel e inclusive havia uma panela de arroz no fogão, ainda quente, que provavelmente seria consumida pelos jovens. O dono da casa, José Carlos de Oliveira, não compareceu ao local mas conseguiram encontrar um documento de identidade dele no imóvel, permitindo assim sua devida identificação. Foram localizadas embalagens plásticas semelhantes as que embalavam o entorpecente, uma faca, Gillettes, também foi apreendido um telefone celular de uso pessoal do adolescente Richard, diante da localização das drogas e demais objetos tudo foi apreendido e conduziram todos ao plantão policial ocasião em que cientificaram Autoridade". Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha José Sebastião Ferreira, que é conhece do acusado, declarou, em Juízo, que: "Não presenciou o contexto fático processado. Relatou, em linhas gerais, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do acusado. Desconhece qualquer envolvimento do acusado com drogas."

Nos termos do art. 209, § 2º, do CPP, "não será computada como testemunha a pessoa que nada souber que interesse à decisão da causa", de modo que o depoimento dessa última testemunha "não contribui para o deslinde do feito" (TJSP - 13ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1501168-29.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. MARCELO SEMER, V.U., j. 26/10/2022, p. 06).

No procedimento para aplicação de medida sócio-educativa instaurado n. 1501982-75.2019.8.26.0400, a parte juvenil representada, para a autoridade policial (fls. 339, 340 e 341), confirmou a prática infracional; para o Ministério Público (fls. 342, 343/344 e 346/347), confirmou o contexto infracional.

Trata-se de prova documental a ser cotejada com toda a prova a ser produzida (TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1502039-93.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FERNANDO GERALDO SIMÃO, V.U., j. 26/10/2022, p. 05/06 ["... não há se falar em nulidade processual pelo uso do depoimento do adolescente envolvido no fato criminoso."]).

* Sr. José Carlos de Oliveira:

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 42).

Negou a prática criminosa.

"Neste ato se faz acompanhado do advogado Leo Cristian Alves Bom, OAB: 268.276, o declarante atualmente não está exercendo nenhuma atividade fixa, faz bicos; Que, a casa em que mora é própria, não possui empregada e é o único que cuida da casa e dos afazeres domésticos; Que, está divorciado e reside sozinho no imóvel; Que, indagado onde estava na data dos fatos, informou que estava na casa da sobrinha DANIELA DE OLIVEIRA, colocando uma pia e cifão na casa dela, a casa dela é próximo ao muro do Hot Beach, perto do tobogã, mas não sabe o nome da rua, nem o número da casa; Que, o declarante foi informado pela vizinha Beatriz por telefone que havia polícia na casa do declarante; Que, por volta das 11:00 horas foi até sua residência mas não tinha mais nenhum policial no local; Que, encontrou a porta arrombada na fechadura, então arrumou por conta própria, que depois retornou para o serviço; Que, almoçou na casa da sobrinha, isso por volta do meio dia; Que, o declarante voltou no final de tarde, por volta das 17 horas e encontrou a porta arrombada novamente, então fechou com uma escora; Que, nada foi furtado do interior de sua residência; Que, no dia seguinte mandou arrumar; Que, indagado sobre o motivo pelo qual não registrou ocorrência e não compareceu nesta delegacia, mesmo depois de saber que a polícia esteve lá, respondeu que tem medo, que é "cagão" (sic), que nunca teve problemas com a justiça; Que, o declarante conhece MARCIO ALVES MIRANDA de vista, pois a mulher dele trabalha na casa ao lado, é uma pousada; Que, é uma casa vizinha a do declarante, no lado direito; Que, não tem amizade com MARCIO ALVES; Que, a mulher de MARCIO não sabe o nome dela; Que, o declarante informa que também trabalha na pousada, faz alguns bicos lá; Que, em relação aos jovens que foram encontrados na casa embalando entorpecentes informa que não sabe como aconteceu isso, que ficou com medo da situação; Que, nega o envolvimento com o tráfico de entorpecentes; Que, no mês passado ficou oito dias de guarda na pousada ao lado da casa em que mora ganhou R\$ 400,00 (quatrocentos reais); Que, a pousada pertence a MARIO PIMENTA; Que, o declarante não possui conta bancária; Que, indagado se é comum entrar pessoas desconhecidas na casa informou que não pode afirmar pois passa o dia fora fazendo bicos, mas acredita que não, a casa não

possui muro frontal e o portão é fechado com uma corrente sem cadeado."

Negou, igualmente, em Juízo (v. TA).

"Por ocasião dos fatos, estava a trabalhar, quando, ao retornar do trabalho, soube, por ouvir dizer, que os adolescentes foram apreendidos na sua casa. Não os conhecia. Lá, deparou-se com a porta e a janela arrombadas. Arrumou-as. Depois da almoço, retornou ao trabalho. Conhece, de vista, as testemunhas Marcio Alves Miranda e Erica Patrícia Victorasso Silva. Antes de sair para o trabalho, deixava a sua comida na panela elétrica. A sua sobrinha (Daniela de Oliveira) tinha cópia da chave da sua residência. Não alegou nada pessoal contra os agentes policiais."

Pois bem.

Com efeito, disserto.

2.1.1 Da utilização ilícita de bem para o tráfico ilícito de drogas ou com seu consentimento

Nos termos do art. 33, § 1º, III, da LD, "quem utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas", configura o crime de utilização ilícita de bem para o tráfico ilícito de drogas ou com seu consentimento.

O tipo penal, vejam, é "quem" (qualquer pessoa) "utiliza" (tornar útil; aproveitar; empregar com vantagem; fazer uso de; tirar utilidade de) "local ou bem de qualquer natureza" (bens) "de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância" (nexo dominial ou detentivo), "ou" (alternatividade típica) "consente" (dar licença; permitir; tolerar; admitir; dar consentimento; concordar; anuir) "que outrem dele se utilize" (usufruto), "ainda que gratuitamente" (animus sine lucro captando), "sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar" (elemento normativo), "para o tráfico ilícito de drogas" (elemento subjetivo específico).

Valho-me, pois, dessa explicação.

Nos termos do art. 156, caput, do CPP, "a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: I - ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida; II - determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante."

Por outras palavras, o ônus da prova incumbe ao autor da ação penal, quanto ao fato constitutivo de seu direito (a prova incriminadora [a ocorrência do contexto criminoso, de acordo com a descrição na petição inicial da ação penal, a autoria delitiva, a materialidade dos fatos e eventuais dados circunstanciais alegados]) (TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500406-47.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALEX TADEU MONTEIRO ZILENOVSKI, V.U., j. 06/06/2022, p. 05), e à parte processada, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (versão exculpatória) do direito do autor da ação penal (TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0001619-70.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. AMARO THOMÉ, V.U., j. 02/09/2019, p. 08; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0000055-02.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. CARLOS EDUARDO ANDRADE SAMPAIO, V.U., j. 30/01/2020, p. 05).

A denúncia, em relação ao contexto fático, é retrospectiva (aspecto subjetivo), mas, em relação às provas, é prospectiva (fonte [aspecto objetivo]) (TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0004887-69.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO, V.U., j. 12/06/2022, p. 12 [... os elementos colhidos a esse título autorizam a condenação do agente, porque os indícios fortalecem o fato indicativo, no âmbito meramente subjetivo da prova, e, além disso, fortalecem o conteúdo dela, agora considerado o seu aspecto objetivo.]); TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500531-44.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FARTO SALLES, V.U., j. 24/06/2022, p. 08), esclareço.

E, nesse aspecto, o Ministério Público (Parquet), posto (apesar de) alegar, não demonstrou a prova incriminadora (contexto fático constitutivo do seu direito).

Os indícios colhidos fora de juízo (fase policial ou inquisitorial), os quais legitimaram o oferecimento e o recebimento da denúncia em face do acusado pela prática do contexto fático previsto no art. 33, § 1º, III, da LD (utilização ilícita de bem para o tráfico ilícito de drogas ou com seu consentimento), consigno, não foram, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), confirmados de forma segura e indene de dúvida (art. 386, VII, do CPP) (STJ – 5ª Turma – AgRg no HC n. 300.212/SP – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 27/10/2015, DJe de 04/11/2015; STJ – 5ª Turma – HC n. 286.582/SP – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 04/10/2016, DJe de 11/10/2016; STJ – 5ª Turma – HC n. 353.232/MG – Rel. Min. JORGE MUSSI, j. 28/6/2016, DJe de 1º/08/2016).

No caso concreto submetido à análise deste magistrado, não há, no pensar deste magistrado, elementos devidamente caracterizados a demonstrar concretamente a conduta (ação) imputada inicialmente ao acusado.

Nenhum dos adolescentes representados ratifica o contexto fático descrito na denúncia, seja perante a autoridade policial (fls. 339, 340 e 341), seja perante o Ministério Público (fls. 342, 343/344 e 346/347).

O quadro de provas produzido não é bastante (suficiente).

De rigor, pois, a absolvição (art. 386, VII, do CPP).

Eis o meu convencimento.

2.1.2 Da associação para o tráfico ilícito de drogas

Nos termos do art. 35, caput, da LD, "associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 'da Lei de Drogas'", configura o crime de associação para o tráfico ilícito de drogas.

O tipo penal, vejam, é "associarem-se" (reunirem-se, juntarem-se, com ânimo de associação, de caráter duradouro e estável) "duas ou mais pessoas" (plurissubjetividade) "para o fim de praticar" (elemento subjetivo específico [finalidade associativa]), "reiteradamente ou não" (habitualidade ou eventualidade executiva), "qualquer dos crimes" apontados com taxatividade pela Lei de Drogas (finalidade associativa).

O que diferencia o crime de associação criminosa específica do tráfico ilícito de

drogas (art. 35, caput, da LD) do concurso de pessoas (art. 29 do CP) é o elemento subjetivo (animus) dos sujeitos ativos do crime.

Exige-se, para a configuração do crime de associação criminosa, a demonstração concreta do vínculo de estabilidade e permanência (associatividade), diferentemente do concurso de pessoas.

Não é suficiente a união ocasional, eventual e episódica.

Para determinar se a reunião era, ou não, eventual, o que não é tarefa fácil, o magistrado atenderá, ao proferir a sentença de mérito, às circunstâncias comportamentais dos sujeitos ativos do crime (critério objetivo), e não ao conhecimento (avaliação pessoal) dos agentes de segurança pública a respeito da fama dos sujeitos ativos (odioso critério subjetivo) (STJ - Sexta Turma - AREsp 1.790.656-SC - Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, p. 04)

O magistrado não julga pessoas, mas atos e fatos.

"E a fama está marcada pela ideia de reputação, aquilo que se diz de alguém" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética - 3. ed. - Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 - São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 105).

Não se exige, para a configuração deste crime autônomo, a efetiva prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD), equiparado ao tráfico ilícito de drogas (art. 33, § 1º, da LD) ou de tráfico ilícito de maquinismos relacionados ao processamento de drogas (art. 34, caput, da LD).

Daí ser desnecessário apreender a droga ou examiná-la.

Valho-me, pois, dessa explicação.

Nos termos do art. 156, caput, do CPP, "a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: I - ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida; II - determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante."

Por outras palavras, o ônus da prova incumbe ao autor da ação penal, quanto ao fato constitutivo de seu direito (a prova incriminadora [a ocorrência do contexto criminoso, de acordo com a descrição na petição inicial da ação penal, a autoria delitiva, a materialidade dos fatos e eventuais dados circunstanciais alegados]) (TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500406-47.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALEX TADEU MONTEIRO ZILENOVSKI, V.U., j. 06/06/2022, p. 05).

A denúncia, em relação ao contexto fático, é retrospectiva (aspecto subjetivo), mas, em relação às provas, é prospectiva (fonte [aspecto objetivo]) (TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0004887-69.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO, V.U., j. 12/06/2022, p. 12 ["... os elementos colhidos a esse título autorizam a condenação do agente, porque os indícios fortalecem o fato indicativo, no âmbito meramente subjetivo da prova, e, além disso, fortalecem o conteúdo dela, agora considerado o seu aspecto objetivo."]; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500531-44.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FARTO SALLES, V.U., j. 24/06/2022, p. 08), esclareço.

E, nesse aspecto, o Ministério Público (Parquet), posto (apesar de) alegar, não demonstrou a prova incriminadora (contexto fático constitutivo do seu direito).

Os indícios colhidos fora de juízo (fase policial ou inquisitorial), os quais legitimaram o oferecimento e o recebimento da denúncia em face do acusado pela prática do contexto fático previsto no art. 35, caput, da LD (associação para o tráfico ilícito de drogas), consigno, não foram, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), confirmados de forma segura e indene de dúvida (art. 386, VII, do CPP) (STJ – 5ª Turma – AgRg no HC n. 300.212/SP – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 27/10/2015, DJe de 04/11/2015; STJ – 5ª Turma – HC n. 286.582/SP – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 04/10/2016, DJe de 11/10/2016; STJ – 5ª Turma – HC n. 353.232/MG – Rel. Min. JORGE MUSSI, j. 28/6/2016, DJe de 1º/08/2016).

O quadro de provas produzido não é bastante (suficiente).

No presente caso dos autos, não há, no pensar deste magistrado, elementos devidamente caracterizados a demonstrar concretamente o caráter associativo da convergência de vontades (animus manendi, intenção de permanecer, ânimo associativo) de se praticar um número indefinido de crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000109-65.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.U., j. 22/01/2020, p. 06), como, por exemplo (verbi gratia), a habitualidade do contato do acusado e dos adolescentes (periodicidade), a confluência dos diálogos (correspondência) e o conteúdo das comunicações (thema).

Não existe prova suficiente (bastante, necessária) de que se tratava de reunião estável e permanente (TJSP – 1ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0003398-60.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. PÉRICLES PIZA, V.U., j. 12/08/2019, p. 11).

O contato deles era meramente ocasional ou episódico.

Não era um verdadeiro pacto associativo, acerto.

Não está evidente a intenção de reiteração delituosa.

Descaracterizada, pois, a associação criminosa específica.

De rigor, pois, a absolvição (art. 386, VII, do CPP).

Eis o meu convencimento.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para o fim de absolver, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, a parte acusada JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, portadora do RG n. 16.518.538 – SSP/SP, da prática do contexto fático denunciado (art. 33, § 1º, III, c.c. o art. 40, VI, da LD e art. 35, caput, c.c. o art. 40, VI, da LD), pois não existe prova suficiente para a condenação; consequentemente (art. 386, parágrafo único, II, do CPP), ordeno a cessação das medidas cautelares (ad cautelam) e provisoriamente aplicadas (art. 282, § 5º, do CPP).

3.1 Das providências preliminares

Expeça-se incontinenti, nos termos dos arts. 409 e 410 das NJCGJ, alvará de soltura clausulado (se por outro motivo não estiver presa) em favor da parte absolvida.

3.2 Das custas processuais

Não há falar (art. 840 do CPP).

3.3 Das comunicações

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt – IIRGD, remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Registrada eletronicamente (art. 389 do CPP e art. 72, §§ 4º e 6º, das NJCGJ). Publique-se (art. 389 do CPP). Intimem-se (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NJCGJ). Oportunamente, arquivem-se os autos.

Estância Turística de Olímpia, 12 de dezembro de 2022⁰.

Eduardo Luiz de Abreu Costa
Juiz de Direito
(Assinado digitalmente)